



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN
IMPERIUM"**

EXPEDIENTE N° 004-2022

CONSORCIO MEFRED CHAMACA
(Demandante)

vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único

Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

Secretaria Arbitral

Abog. KATY LINA CADILLO VALENZUELA

Huánuco, 21 de julio de 2023.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN N°

Huánuco, 19 de julio de 2023.

VISTOS: El expediente Arbitral.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

DATOS GENERALES:

Demandante : Consorcio Mefred Chamaca

Demandada : Municipalidad Distrital de Chamaca
: RUC N° 20172494952

Contrato : Contrato de Ejecución de Obra fecha 24 de noviembre del 2017, devenida de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, correspondiente a la ejecución de obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego en la Comunidad de Uchucarcco Anexos de Kerakera, Qollotapampa, Coparay-Janapampa y Uchucarcco Bajo Wincho, Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco".

Monto del contrato : S/ 20'779,448.24 (Veinte Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 24/100 Soles).

Fecha de convocatoria: 22 de setiembre de 2017.

inicio del arbitraje : 17 de enero de 2022.

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Controversias relacionadas a las siguientes materias:

- Penalidades
- Pago de intereses.
- Condena de costas y costos arbitrales.

Katy Lina Cádiz Valenzuela
SECRETARIA ARBITRAL

ABREVIATURAS:

Centro: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

Contrato: Contrato de Ejecución de Obra fecha 24 de noviembre del 2017, devenida de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, correspondiente a la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego en la



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Comunidad de Uchucarcco Anexos de Kerakera, Qollotapampa, Coparay-Janapampa y Uchucarcco Bajo Wincho, Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco”.

El Contratista o el Demandante: Consorcio Mefred Chamaca

La Entidad o la Demandada: Municipalidad Distrital de Chamaca

Las partes: Conjuntamente el Demandante y la Demandada.

LCE: Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, modificada por Decreto Legislativo N° 1341.

Ley de Arbitraje: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

Proceso de Selección: Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, correspondiente a la ejecución de la obra: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego en la Comunidad de Uchucarcco Anexos de Kerakera, Qollotapampa, Coparay-Janapampa y Uchucarcco Bajo Wincho, Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco”

Reglamento: Reglamento del Centro de Arbitraje.

RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

2. MARCO INTRODUCTORIO:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

En la ciudad de Huánuco a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), la Árbitro Único, luego de llevar a cabo las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, habiendo escuchado sus argumentos sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, ha realizado un análisis sobre todo lo debatido y los medios probatorios aportados, por lo que dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE:

Razón Social: Consorcio Mefred Chamaca

Representante: Frank Ortiz Garay

PARTE DEMANDADA:

Razón Social: Municipalidad Distrital de Chamaca

Representante: Domingo Salas Centeno

[Firma]
M. de la Torre Santos de Alvarado
ARBITRO UNICO

CONVENIO ARBITRAL:

"Cláusula Vigésima: Solución de Controversias".

"... Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado o en su defecto en el inciso 45.2 del artículo 45 de la ley de contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. La entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco y Centro de Arbitraje del OSCE siendo la sede Arbitral en la ciudad de Cusco.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado..."

COMPETENCIA ARBITRAL

[Firma]
Katy Lina Cádiz Valenzuela
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Conforme indica la Cláusula Vigésima del contrato y estando al acuerdo de las partes, se estableció la competencia del centro y su reglamento para conocer la presente causa, tanto más si dicha Cláusula Vigésima indica solo una "propuesta" de la entidad para ver el arbitraje, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también al artículo 189.1 del RLCE y el Principio de autonomía de la voluntad o voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

DESIGNACIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

La abogada Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, ha sido nombrada Árbitro Único, de acuerdo con el Reglamento del Centro y con la conformidad de las partes.

TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato de Ejecución de Obra fecha 24 de noviembre del 2017, devenida de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, se dispuso la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego en la Comunidad de Uchucarcco Anexos de Kerakera, Qollotapampa, Coparay-Janapampa y Uchucarcco Bajo Wincho, Distrito de Chamaca - Chumbivilcas - Cusco".

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

3.1. Con fecha 16 de marzo de 2023 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA con REG CAH N° 1853, como demandante el CONSORCIO MEFRED CHAMACA debidamente representada por el señor RICARDO SANTOS CHAVEZ GARAY, quien se identifica con DNI N° 43957001, y la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca debidamente representado por el abogado Efraín Mora Jorge, con Reg. C.A.C. N° 4820.

3.2. Con fecha 30 de marzo de 2023 el demandante presenta su demanda arbitral.

3.3. Mediante Resolución N° 001-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 03 de abril de 2023, el tribunal declaro inadmisibile la demanda por la falta del pago del adelanto de gastos arbitrales de las partes.

Katy Lina Caceres Valenzuela
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

- 3.4.** Mediante Resolución Arbitral N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 se admitió a trámite la demanda y se corrió traslado al demandado, señalándose fecha para la Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.
- 3.5.** Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 31 de mayo de 2023, se declara renuente a la demandada al no haber absuelto el traslado con la demanda, se fijan los puntos controvertidos y se admiten las pruebas, otorgándose un plazo a las partes para que presenten sus alegatos finales.
- 3.6.** Mediante Resolución Arbitral N° 04-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 26 de junio de 2023 se declara la causa expedita para laudar dentro del plazo de quince días.
- 3.7.** Mediante escrito presentado de manera virtual el 05 de julio de 2023, se apersona el Abg. Walter Martiarena Rios, en nombre y representación de la demandada, y solicita la nulidad del acta de instalación y Resolución Arbitral N° 04-2023/CACI/AU/HITS/HCO.
- 3.8.** Mediante Decreto N° 03-2023 de fecha 05 de julio de 2023, se corre traslado a la parte demandante con el escrito de nulidad del acta de instalación y Resolución Arbitral N° 04-2023/CACI/AU/HITS/HCO, presentado por la demandada.
- 3.9.** Con fecha 08 de julio de 2023, el demandante presenta por medio virtual su escrito N° 09, mediante el cual absuelve el traslado conferido con la nulidad deducida.

Katy Lina Cadillo Valenzuela
SECRETARIA ARBITRAL

4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

4.1. CUESTIÓN PREVIA

En forma previa al análisis de la materia controvertida y valoración de los medios probatorios admitidos por el Árbitro Único en el presente arbitraje, corresponde señalar que:

Del Marco Legal

En lo que concierne al marco normativo que se aplica a la relación contractual celebrada, es de mencionar que ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. Consecuentemente, la ley aplicable al



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

fondo de la controversia es la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento en su texto aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. De igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Respecto a la designación del Árbitro Único

La designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las partes, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

Del ejercicio legítimo del derecho de defensa de las partes

El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada y su procuraduría fueron debidamente emplazadas con dicha demanda, la misma que no fue contestada, no presentando reconvenición dentro del plazo.

Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por el Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver.

Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento el Árbitro Único su irrestricto ejercicio del derecho de defensa en igualdad de condiciones en resguardo del debido proceso.

Respecto a la Nulidad deducida por la demandada

Conforme al escrito presentado por la demandada, de manera virtual, el 05 de julio de 2023, por el cual se apersona el Abg. Walter Martiarena Ríos, solicitando la nulidad del acta de instalación del tribunal arbitral y la Resolución Arbitral N° 04-2023/CACI/AU/HITS/HCO por supuesta vulneración al debido procedimiento y a su derecho a la defensa; dicho recurso, mediante Decreto N° 03-2023 de fecha 05 de julio de 2023, se corrió traslado a la parte demandante, quien con fecha 08 de julio de 2023 presenta por medio virtual su escrito N° 09 absolviendo el traslado conferido con la nulidad deducida



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Respecto a la nulidad procesal arbitral, ASTUHUAMÁN BALDEÓN¹ nos indica que: "... Siendo el proceso un procedimiento que tiene un punto de inicio (acto de inicio) y un punto de fin (acto final), conformado por una serie de actos procesales concatenados, vale decir, dependientes unos de otros, es posible que en su recorrido se presenten actos procesales que no se realicen de acuerdo a las exigencias preestablecidas en la ley; es decir, actos procesales que no cumplan con una determinada *fattispecie*. A estos actos procesales se les llaman actos procesales viciados, pues son actos que no se adecuan al supuesto de hecho de la disposición normativa. A lo largo del procedimiento muchos actos procesales pueden presentarse viciados; algunos de ellos, relevantes y otros intrascendentes. Sin embargo, trascendentes o intrascendentes son actos viciados. Ahora bien, cuando en el procedimiento una de las partes o el tercero que resuelva la controversia (sea un juez o un árbitro) advierta la existencia de un acto viciado, le corresponderá a éste determinar si dicho acto se debe declarar (*rectius*: decretar) nulo o no. En tal sentido, la nulidad vendría a ser una decretación del tercero imparcial (que para el presente trabajo sería el árbitro) respecto de un acto procesal viciado, lo que nos lleva a concluir que para decretarse una nulidad debe existir necesariamente un vicio, pues sin vicio no puede haber nulidad (...)

Vicios formales

Explica Cavani que los vicios formales "hacen alusión a un acto defectuoso por el incumplimiento de la forma (en sentido estricto) prevista legalmente para su realización". Esto no es otra cosa más que los requisitos formales para la realización de los actos procesales. Así, como ejemplo, tenemos a los artículos 119 (que dispone la forma de eliminar palabras o frases equivocadas), 122 (que señala la indicación del lugar, fecha o numeración correlativa de las resoluciones), 124 (que hace referencia al plazo para expedir las resoluciones, sean éstas un decreto, auto o sentencia) y 131 (que hace mención a la firma de la parte, el representante o el abogado) de nuestro CPC, por citar algunos casos (...)

Vicios extra formales

Siguiendo nuevamente a Cavani, diremos que los vicios extra formales "son aquellos relacionados con el válido ejercicio de los poderes del juez y las partes en el proceso" (para el presente trabajo, del válido ejercicio del árbitro y las partes en el proceso arbitral). Cavani pone de ejemplo para el proceso civil a "la capacidad procesal, la competencia y la imparcialidad"; es decir, a los requisitos de validez abarcados en lo que se conoce como "presupuestos

¹ Astuhamán Baldeón, J. (2016). La nulidad en el arbitraje: notas introductorias a un instituto "silenciado" por nuestra Ley de Arbitraje. *Revista De La Maestría En Derecho Procesal*, 6(1). Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprosesal/article/view/93-124>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

procesales". Con algunos matices, considero que la competencia, la capacidad procesal y la imparcialidad también son conceptos que sirven como "presupuestos procesales" para un proceso arbitral, pues ellas permiten que la decisión a emitirse sea válida..."

Ahora bien, a nivel administrativo, tal como señala ASCENCIOS TORRES², podríamos indicar que "la nulidad es una sanción que la norma prevé para determinadas situaciones o actuaciones jurídicas irregulares y cuando con ellas se viola el derecho de defensa o al debido proceso de alguna de las partes (...) Para que exista nulidad, ella debe generarse en una causa original, ya existente al nacimiento del acto, por ejemplo; falta de capacidad de ejercicio o inobservancia de la forma prevista por la ley para la validez del acto. Su ilicitud, es consecuencia de su imposibilidad física o material o la presencia de vicios de la voluntad. La nulidad debe ser entendida como una sanción que priva al acto de la atribución de poder producir sus efectos normales, propios de un acto legal y legítimo (...) La nulidad absoluta de pleno derecho, o nulidad ipso jure, se da cuando el acto administrativo adolece de cualquiera de sus requisitos esenciales o requisitos de validez: autoridad competente, objeto o contenido legal finalidad pública, motivación adecuada y procedimiento regular previsto por la ley, y además haber incurrido en cualquiera de los supuestos que están establecidos en el Art. 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General".

Así las cosas, corresponde determinar la concurrencia de los supuestos vicios sobre el acta de instalación y la Resolución Arbitral N° 04-2023/CACI/AU/HITS/HCO, sean estos vicios formales o extra formales:

- En primer lugar, la demandada alega una falta de autorización expresa del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chamaca a favor del Abg. Efraín Mora Jorge, el mismo que participo de los actos impugnados, en razón que dicho letrado sólo justifico su apersonamiento en base al Memorándum N° 0278-2023-FAAB-GM-MDCH-CH/C de fecha 07 de marzo de 2023, suscrita únicamente por el Gerente Municipal Econ. Fredy A. Almanza Barriga y no por el precitado alcalde, como era correcto.

Sobre dichos argumentos, debemos indicar que conforme señala el artículo 38 de la Ley de Arbitraje:

Artículo 38.- Buena fe.

² ASCENCIOS TORRES, PASCUAL. Manual Auto Instructivo "VALIDEZ Y NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO". <http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/686/MANUAL%20CURSO%20VALIDEZ%20Y%20NULIDAD%20DEL%20ACTO%20ADMINISTRATIVO.pdf?sequence=4&isAllowed=y>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje.

En tal sentido, las actuaciones que tienen las partes durante la tramitación del proceso, ya sea presentando escritos, informes, pericias, alegatos y/o toda participación oral, se encuentra revestida de la buena fe procesal ya que, en palabras de RODRÍGUEZ ARDILES³, obliga de manera universal, esto es, a todos sin excepción a cumplir una determinada conducta, actitud o comportamiento, dentro de los estándares de lealtad, respeto, seguridad y confianza, en el quehacer de la relación convenida o pactada, a efectos de que la contraparte, actuando de igual forma, tenga la certeza de que cualquiera que sea la circunstancia que se enfrenta con su contraparte, han de accionar de conformidad a esos postulados, y que de manera conjunta e incluso individual, se entiende como buena fe.

La aplicación de la buena fe abarca, por tanto, el accionar cuando se ejerce o reclama un derecho, así como cuando se cumple el deber proveniente de la obligación pactada. Por lo tanto, el apersonamiento hecho por el Abg. Efraín Mora Jorge, a través del Memorándum N° 0278-2023-FAAB-GM-MDCH-CH/C de fecha 07 de marzo de 2023, mediante el cual acude ante el tribunal arbitral en representación de la Municipalidad Distrital de Chamaca, es un acto válido y eficaz pues ha sido realizado con las formalidades previstas por el Acta de Instalación y en concordancia con la Ley de Arbitraje, tanto más, si tenemos en cuenta que el Memorándum N° 0278-2023-FAAB-GM-MDCH-CH/C ha sido suscrito por el Gerente Municipal de dicha comuna, quien por imperio del numeral 20 del artículo 20° de la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", se observa que el alcalde delegó sus atribuciones administrativas en el gerente municipal, hecho que por cierto no ha sido desvirtuado ni por el impugnante ni mucho menos por el titular de dicho pliego.

En lo que respecta a la vulneración al derecho a la defensa, resulta adecuado e interesante también traer a colación lo señalado por la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 03841-2012-PA/TC, que en su fundamento 4, señala: "Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha

³ RODRÍGUEZ ARDILES, Ricardo. La buena fe procesal en el arbitraje. Revista Peruana de Derecho de la Empresa: Temas actuales de Derechos Arbitral N° 75. Lima-Perú. 2021. Pág. 127.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

*precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una **material**, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra **formal**, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050-2002-AA/TC, fundamento 12º).*

Así las cosas, de los actuados arbitrales podemos observar que ya sea durante la fase de solicitud arbitral, instalación del tribunal arbitral, fase postulatoria y de contestación, hasta la actualidad y durante todos los actos procesales realizados, la demandada siempre ha estado debidamente representada por los sucesivos abogados que ejercieron su defensa, máxime si tenemos en cuenta que las notificaciones cursadas durante todo el proceso no han sido cuestionadas bajo ninguna forma, por ende el derecho de ejercer su defensa le ha sido plenamente garantizado a ambas partes procesales, por lo que debe desestimarse el pedido de nulidad en este extremo.

- Alega también la demandada que su incomparecencia a la diligencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, programada para el 31 de mayo de 2023, se debió a que para ese mismo día y hora tenía programado el Simulacro Multipliego convocado por INDECI a nivel nacional, lo cual impidió que pudiera asistir a dicha diligencia.

Al respecto, la nulidad es una sanción del tercero imparcial respecto de un acto o actos procesales viciados, cuando con ellas se viola el derecho de defensa o al debido proceso de alguna de las partes; en tal sentido, un acto para ser considerado nulo debe vulnerar tales derechos, lo cual no ocurre en el presente caso ya que al encontrarse debidamente notificadas las partes, estas se encuentran obligadas a concurrir a las diligencias programadas por el tribunal arbitral, salvo causa debidamente justificada y sustentada en hechos de caso fortuito o de



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

fuerza mayor; entonces, la situación descrita por la demandada respecto a su incomparecencia a raíz del Simulacro convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para aquella fecha, no es una causa que justifique su inasistencia en razón que dicho simulacro estuvo programado desde el 19 de enero de 2022, tal como se observa de la Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM, por lo tanto, la demandada conocía desde aquella fecha la realización del simulacro y pudo muy bien prever su comparecencia a la audiencia señalada y/o solicitar la reprogramación correspondiente, por lo que debe desestimarse el pedido de nulidad en este extremo.

- Señala también la demandada que: "... además que no contaba con facultades expresa por el principio de literalidad del alcalde, dado que asumí en fecha recientemente el cargo de abogado de defensa judicial y el alcalde se hallaba de viaje fuera de la jurisdicción..."

Al respecto, este tribunal arbitral considera que conforme a las reglas establecidas en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral y las indicadas en la Ley de Arbitraje, las partes asumen responsabilidad sobre los plazos, mecanismos y comparecencia a las actuaciones procesales que se emitan durante el proceso arbitral, lo que implica también el deber de prever su asistencia a las diligencias que señale el Tribunal Arbitral, máxime si tenemos en cuenta que por el Principio de Informalismo, concordante con los numerales 1 y 2 del artículo 37° de la Ley de Arbitraje, las partes podrán comparecer personalmente ante el tribunal arbitral o bien estar representadas por abogado o por cualquier otra persona, contando únicamente con autorización por escrito, sin mayor formalidad, por ende los argumentos de la demandada devienen en infundados, por lo que debe desestimarse el pedido de nulidad en este extremo.

- Finalmente, la demandante señala: "... el centro de arbitraje que tramita el caso no podría pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones planteadas por el demandante consorcio Mefred chamaca, dado que la parte contraria no ha cumplido con formular su demanda en el plazo de 10 días que tenía para hacerlo y como tal el accionado no podría hacer defensa alguna, tampoco imponer ninguna medida ni sanción de carácter pecuniario, porque vulneraría sus propias reglas y que la misma no ha sido aprobada por esta parte conforme se ha advertido precedentemente..."



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Al respecto y tal como ya señalamos en el numeral 3 de la presente resolución, el proceso ha seguido con normalidad, habiéndose absuelto los recursos planteados por las partes y dentro de los plazos establecidos por el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, tanto más que durante el proceso la demandada no ha ejercido su derecho a contestar la demanda presentada previamente por su contraparte, ni mucho menos se han deducido excepciones o cuestiones previas, garantizándose durante todo momento el derecho a la defensa y el debido proceso que reviste la presente causa, por lo que debe desestimarse el pedido de nulidad en este extremo.

Bajo la premisa expuesta, queda evidenciado que los argumentos de la demandada para sustentar su nulidad, son claramente infundados, pues con ellos se evidencia un desconocimiento a los actos procesales en el que participaron ellos mismos, garantizándose en todo momento su derecho a la defensa y al debido proceso.

En consecuencia, conforme a lo señalado precedentemente, puede establecerse que no se ha producido ningún vicio sancionado con nulidad sobre el acta de instalación del tribunal arbitral y la Resolución Arbitral N° 04-2023/CACI/AU/HITS/HCO; por lo que dicha solicitud deviene en **INFUNDADA**, correspondiendo entrar sobre el fondo de la controversia.

Del Laudo:

El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido.

Por otro lado, se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

De igual forma, el Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

Finalmente, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

5. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 31 de mayo de 2023, se fijan los siguientes puntos controvertidos:

- ❖ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no declarar nula y sin efecto legal la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C emitidas por la Municipalidad Distrital de Chamaca, por la que resuelven aplicar penalidades por la suma de S/ 128,832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles); y en su lugar se declare absuelto al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en los ítems 8, 13 y 22 de la Clausula Décimo Quinto del Contrato de Ejecución de Obra, así como de los hechos descritos en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022 y "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022. Determinar si la entidad ha emitido pronunciamiento respecto a la liquidación técnica financiera representada por el contratista.
- ❖ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no declarar nula y sin efecto legal la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C emitidas por la Municipalidad Distrital de Chamaca, por la que resuelven aplicarnos penalidades por la suma de S/ 145,456.13 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 13/100 soles); y en su lugar se declare absuelto al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en los ítems 13 y 22 de la Clausula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, así



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

como de los hechos descritos en el Acta de Verificación de Obra N° 04 de fecha 18 de febrero de 2022 y Acta de Verificación de Obra N° 05 de fecha 01 de abril de 2022.

❖ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, la devolución y/o reembolso a favor del contratista, del monto de S/ 128,832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles) indebidamente descontados, más los intereses generados hasta la fecha.

❖ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, la devolución y/o Reembolso a favor del contratista, del monto de S/ 145,456.13 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con 13/100 soles) indebidamente descontados, más los intereses generados hasta la fecha.

❖ **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que se ordene a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral, así como los gastos del abogado patrocinante del demandante.

6. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el numeral 7 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, la Árbitro Único considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios presentados por el DEMANDANTE

- Contrato de Ejecución de Obra fecha 24 de noviembre del 2017.
- Bases integradas de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH- Primera Convocatoria.
- Cargo de notificación vía correo electrónico de fecha 05 de setiembre de 2022.
- Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/c.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH.
- Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra.
- Contrato N° 117-2021-OAL-MDCH/CH.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 173-2021-GM/MDCH-CH.
- Informe N° 006-2022-CMCH/HMZD-RO.
- Informe N° 08-2022-REPLEGLA/SIUCH.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

- Informe N° 007-2022-CMCH/HMZD-RO.
- Informe N° 09-2022-REPLEGLA/SIUCH.
- Cargo de notificación vía correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2022.
- Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH.
- Acta de Verificación de Obra N° 04.
- Acta de Verificación de Obra N° 05.
- Informe N° 183-2022-BJBH-OSELO/MDCH.
- Informe N° 1584-2022-CHVM/SGIDUR-MDCH-CUSCO.
- Informe N° 049-2022-RMP-OLYBP/MDCH.C.
- Opinión Legal N° 300-2022-OAL-MDCH-HHCM.

Medios probatorios presentados por el DEMANDADO

La Arbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 y constando la notificación a folios 406 del expediente arbitral, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, por lo que se le declaró renuente.

7. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar nula y sin efecto legal la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C emitidas por la Municipalidad Distrital de Chamaca, por la que resuelven aplicar penalidades por la suma de S/ 128,832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles); y en su lugar se declare absuelto al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en los ítems 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinto del Contrato de Ejecución de Obra, así como de los hechos descritos en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022 y "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022. Determinar si la entidad ha emitido pronunciamiento respecto a la liquidación técnica financiera representada por el contratista.

Resumen de la posición del DEMANDANTE



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.1. La demandante señala que con fecha 05 de setiembre de 2022 se le notifica, vía correo electrónico, la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C de fecha 12 de agosto de 2022 (carta que no fue diligenciada notarialmente), adjuntando la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH de fecha 05 de agosto de 2022, con la que se le aplica penalidad por un monto de S/128, 832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles), por la supuesta comisión de las infracciones contenidas en los ítems 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, y cuyo sustento se encuentra contenido en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022 y "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022.

7.2. La demandante señala que la aplicación de dichas penalidades transgrede el procedimiento establecido por las bases integradas y el contrato, pues adolece de los siguientes vicios: i) No se ha registrado en cuaderno de obra las infracciones cometidas y las evidencias recabadas; ii) No se ha notificado al contratista la carta de preaviso de aplicación de penalidades; iii) No se ha otorgado al contratista el plazo para subsanar la infracción; y iv) Las penalidades no cuentan y no tienen su origen en el informe del Supervisor de Obra, Ing. Luis David Aedo Bellota, sino que las mismas han sido impuestas por el Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, Ing. Becquer Julio Bustinza Herrera.

7.3. Del mismo modo, la demandante señala que las penalidades transgreden el procedimiento establecido en los ítems 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, y el Capítulo III- Requerimiento, página 52 de las Bases Integradas.

7.4. Por otro lado, la demandante también indica que ya fue eximido y/o absuelto por la Supervisión de Obra, de la comisión de las penalidades indicadas en la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, incluso con fecha anterior a la notificación con dicha resolución, ello conforme a:

- a) Informe N° 006-2022-CMCH/HMZD-RO recepcionada por la supervisión con fecha 12 de mayo de 2022, mediante la cual levanta las Observaciones indicadas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

- b) Informe N° 08-2022-REPLEGLA/SIUCH de fecha 13 de mayo de 2022, mediante el cual la supervisión, verifica que el contratista ha justificado y subsanado las observaciones indicadas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022.
- c) Informe N° 007-2022-CMCH/HMZD-RO recepcionada por la supervisión con fecha 17 de mayo de 2022, mediante la cual levanta las Observaciones indicadas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022.
- d) Informe N° 09-2022-REPLEGLA/SIUCH de fecha 20 de mayo de 2022, mediante el cual la supervisión, verifica que el contratista ha justificado y subsanado las observaciones indicadas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.5. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 y constando la notificación a folios 406 del expediente arbitral, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.6. La definición de penalidad la encontramos en la legislación civil, siendo que el artículo 1341 del Código Civil nos dice que es el pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, la cual tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior.
- 7.7. Por su parte, el RLCE contempla 02 tipos de penalidades: la penalidad por mora y otras penalidades; siendo la penalidad por mora aquella impuesta ante el incumplimiento injustificado de los plazos contractuales, y pudiendo además establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora con la finalidad de desincentivar el incumplimiento del contratista y resarcir posibles perjuicios que se pudiera causar a la entidad.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.8. De la misma forma, la Opinión N° 003-2022/DTN señala que en los documentos del procedimiento de selección se puede establecer otras penalidades, siempre y cuando éstas sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Ahora, como expresión de tales características, especialmente de la objetividad, el Reglamento ha precisado que en los documentos del procedimiento de selección debe contemplarse: (i) los supuestos de aplicación de penalidad; (ii) la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto; y, (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Ahora bien, la Opinión N° 023-2017/DTN nos da mayor alcance al respecto y señala:

- i)** La objetividad implicaba que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serían penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificaría la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación;
- ii)** Por su parte, la razonabilidad implicaba que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicarían al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento, y;
- iii)** La congruencia con el objeto de la convocatoria implicaba que se penalizara el incumplimiento de alguna obligación comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria.

7.9. Para nuestro caso, la controversia esta referida a la aplicación de "otras penalidades" distintas a la penalidad por mora, materializadas a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, razón por la que el tribunal procede a verificar si la misma ha sido aplicada observando los requisitos señalados por el artículo 134 del RLCE, esto es, que se haya cumplido con incluir los supuestos de aplicación de la penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

7.10. Resulta pertinente indicar que las penalidades aplicables al presente contrato deben ser analizadas e interpretadas bajo su forma literal, pues, tal como señala FERNÁNDEZ CRUZ⁴, *el método interpretativo literal es el primer*

⁴ FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil Peruano. Pág. 152. Obtenido del enlace: <file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-IntroduccionAlEstudioDeLaInterpretacionEnElCodigoC-7792763.pdf>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

método que utiliza un intérprete respecto a un contrato específico, dado que el mismo nos ofrece la primera aproximación a lo que es el contrato en sí, el cual expresa la voluntad de las partes. Por esto, la doctrina comparada ha abandonado la regla "in claris non fit interpretatio" en su sentido estricto y rígido, señalándose al respecto que: "... la regla in claris puede tener dos significados. Según su significado más rígido, ella quiere decir que la interpretación extratextual interviene cuando el texto sea, alternativamente, lagunoso o contradicho por indicios externos...". Agregando además que "... El verdadero problema no se refiere al tratamiento de la declaración clara. El verdadero problema consiste en esclarecer si una declaración, intrínsecamente clara, puede devenir oscura por efecto de indicios extratextuales...".

- 7.11.** Ahora bien, el contrato que vincula a las partes es eminentemente un contrato celebrado con la administración pública y, por ende, conforme a la construcción doctrinaria, se le denomina como un contrato administrativo. En palabras del tratadista GUZMÁN NAPURÍ⁵, un contrato administrativo es:

"... Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo".

- 7.12.** En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *ius imperium*, para someterse a un esquema de contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamiento que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual. Corroboramos nuestra posición lo expuesto por el tratadista HUAPAYA TAPIA⁶, quien expone:

"(...) En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de "privilegios", "poder" y "actuaciones unilaterales"

⁵ GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General (2005). Pág. 320.

⁶ HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano. en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima. 2012. Pág. 542.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las "cláusulas exorbitantes" o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual."

Estando a lo expuesto por el precitado jurista, en un contrato administrativo, tal como lo es el Contrato de Ejecución de Obra fecha 24 de noviembre del 2017, la administración pública conserva para sí, su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar estados jurídicos, constituirán indefectiblemente un acto administrativo, tal como lo vienen a ser la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH y demás sustentos emitidos por la ahora demandada.

- 7.13.** Entonces, habiendo definido que, en el marco de una contratación pública, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos y por ende, sujetos y regulados por la LPAG y la Ley, lo cual no implica un desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, siendo así, se procederá con el análisis del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos de debida motivación y competencia, previstos en el artículo 3° de la LPAG, que indica:

*"Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:*

- 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.*
- 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.*
- 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad,*



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación."

7.14. Respecto a los supuestos de aplicación de esas "otras penalidades": es pertinente indicar que según el Anexo Único - Anexo Definiciones, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 116 de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes; de igual forma, dentro del ordenamiento en materia de contrataciones es comúnmente aceptado el hecho que los supuestos a penalizar deben de estar correctamente definidos en el contrato, ya que hacer lo contrario sería inobservar el criterio de objetividad establecido por la propia norma.

7.15. Para nuestro caso, la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, imputa la comisión de las infracciones señaladas en los numerales 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del contrato:

TABLA DE PENALIDADES - CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	PROCEDIMIENTO	FORMA DE CALCULO
8	El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el inspector y/o supervisor designado	Según informe del inspector o supervisor designado	0.0002*M (por día y ocurrencia)
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del inspector o supervisor designado	0.002*M (por día y ocurrencia)
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su oferta técnica	Según informe del inspector o supervisor designado	0.0010*M (por ocurrencia)

DE LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE CÁLCULO DE LAS PENALIDADES

TABLA DE PENALIDADES - CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS					
N°	DEFINICIÓN	CALCULO	M = MONTO CONTRACTUAL	NUMERO DE DÍAS O NÚMERO DE VECES DE OCURRENCIA	TOTAL S/.
8	El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el inspector y/o supervisor designado	0.0002*M	20,779,448.24	1 según acta de inspección o visita inopinada, de fecha 16 de mayo 2022	4,155.89
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	0.002*M	20,779,448.24	2 según acta de inspección o visita inopinada de fecha 11 y 16 de mayo 2022	83,117.79
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su oferta técnica	0.001*M	20,779,448.24	2 según acta de inspección o visita inopinada, de fecha 11 y 16 de mayo 2022	41,558.90
TOTAL					S/. 128,832.58



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.16. Por su parte, los numerales 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato enumeran los supuestos a penalizar:

8	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el inspector y/o supervisor designado	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0002*M (Por día y ocurrencia)
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.002*M (Por día)
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su Oferta Técnica	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0010*M (Por ocurrencia)

7.17. Como podrá observarse, es el contrato en sí mismo, a través de su Cláusula Décimo Quinta, quien delimita y enumera los supuestos a penalizar, no advirtiéndose contradicción o vicios sobre su contenido textual ni sobre los supuestos invocados por la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, pues resultan claras las conductas a ser sancionadas, concluyéndose que las penalidades aplicadas si cumplen con este presupuesto.

7.18. Respecto a la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto: Sobre este presupuesto, deberemos remitirnos nuevamente a los numerales 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, por cuanto en ellas se especifica la forma de cálculo de cada supuesto penalizable, así tenemos que:

8	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el inspector y/o supervisor designado	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0002*M (Por día y ocurrencia)
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.002*M (Por día)
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su Oferta Técnica	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0010*M (Por ocurrencia)

7.19. Como podrá observarse, es el contrato en sí mismo, a través de su Cláusula Décimo Quinta, quien especifica claramente la forma de cálculo de la



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

penalidad para cada supuesto, no advirtiéndose contradicción o vicios sobre su contenido textual ni sobre el cálculo realizado por la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, concluyéndose que las penalidades aplicadas si cumplen con este presupuesto.

7.20. Respecto al procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar: Sobre este presupuesto, deberemos remitirnos nuevamente a los numerales 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, por cuanto en ellas se especifica el procedimiento de verificación, así tenemos que:

8	El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el inspector y/o supervisor designado	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0002*M (Por día y ocurrencia)
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.002*M (Por día)
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su Oferta Técnica	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0010*M (Por ocurrencia)

7.21. Del mismo modo, las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, en su Capítulo III- Requerimiento, página 52, señalan que:

OTRAS PENALIDADES

Las consideraciones de la aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas obligaciones a cargo de El Contratista distintas al retraso, cuyas consideraciones están definidas en el artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de penalidades – contrato de obras, registra la infracción en el cuaderno de obras, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso a El Contratista; de igual forma un representante de la Entidad que administra el contrato puede advertir la falta mediante carta de preaviso al Contratista, estableciéndole un plazo para la subsanación de la infracción. En caso se advierta, del cuaderno de obra, la reincidencia de infracciones, el Supervisor calculara directamente la penalidad.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, El supervisor procede a calcular la penalidad según la tabla establecida de penalidades sobre un porcentaje del monto contractual, por día, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto

7.22. Como podrá observarse, tanto las bases integradas como el contrato, en ambos documentos se ha indicado el procedimiento para la aplicación de



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

esas "otras penalidades", sin embargo, realizando un análisis del sentido de tales documentos se puede advertir que las Bases Integradas complementan al Contrato en sí mismo, ya que del texto de ambas no se aprecia contradicciones o incongruencias procedimentales, al contrario, las Bases Integradas hacen un desarrollo un poco más amplio del procedimiento a seguir en caso se presenten o se configuren estos hechos penalizables; en buena cuenta y dada la complementariedad del contrato y los documentos que la conforman, podemos enumerar el procedimiento establecido por el contrato para la aplicación de esas "otras penalidades":

- a) El supervisor registra la infracción en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias de los hechos penalizables.
- b) El supervisor remite un preaviso al contratista, otorgándole un plazo para la subsanación de la infracción.
- c) En caso de no subsanar la infracción, el supervisor procede a emitir informe sobre las penalidades a aplicarse, haciendo el cálculo respectivo, verificando antes que no se haya alcanzado el tope máximo de penalidades.
- d) En caso de verificarse en el cuaderno de obra la reincidencia del contratista, se aplican las penalidades directamente mediante informe del supervisor.

7.23. Entonces, revisando el procedimiento seguido por la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH y los documentos que la sustentan, tales como el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022, "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022, Informe N° 280-2022-BJBH-OSELO/MDCH de fecha 05 de julio de 2022, Informe N° 0748-2022-CHVM/SGIDUR-MDCH-CUSCO de fecha 05 de julio de 2022, e Informe N° 141-2022-RJTE-OLyBP/MDCH-C de fecha 26 de julio de 2022, de ninguna de ellas se observa que se haya seguido el procedimiento indicado en el fundamento 7.19 de la presente resolución, es más, de una revisión minuciosa de la documentación aportada se ha podido advertir que las penalidades han sido aplicadas por el Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Chamaca de aquel entonces, Ing. Becquer Julio Bustinza Herrera, pero no se observa la participación de la Supervisión de Obra que recaía sobre el Ing. Luis Aedo Bellota. Con ello se contraviene lo indicado por la Cláusula Décimo Quinta del Contrato y las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, por cuanto ambos documentos



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

dejan claramente establecido que quien aplica y cuantifica las "otras penalidades" es el Supervisor de Obra.

7.24. Sumado a ello, corresponde hacer la precisión que la omisión de la demandada en seguir el adecuado procedimiento para la aplicación de "otras penalidades" ha sido revertida o corregida por la propia Supervisión de Obra (Consorcio Supervisor A&A, representando por el Ing. Luis David Aedo Bellota) quien a través de los siguientes documentos ha tenido por justificadas y subsanadas las supuestas conductas penalizables:

- Informe N° 08-2022-REPLEGLA/SIUCH de fecha 13 de mayo de 2022, mediante el cual se verifica que el contratista ha justificado y subsanado las observaciones indicadas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022, conforme a los descargos efectuados mediante Informe N° 006-2022-CMCH/HMZD-RO.
- Informe N° 09-2022-REPLEGLA/SIUCH de fecha 20 de mayo de 2022, mediante el cual se verifica que el contratista ha justificado y subsanado las observaciones indicadas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022, conforme a los descargos efectuados mediante Informe N° 007-2022-CMCH/HMZD-RO.

7.25. En esa lógica, la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH en sí misma y la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C, como medio para dar a conocer una determinada situación jurídica al demandante, adolecen de la debida motivación; dado que todo acto administrativo esté contenido en una carta, oficio o resolución administrativa debe considerar las razones, lógica y razonamiento de la decisión que ha tomado el funcionario que emite el resolutivo, en otros términos, exponer en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada, es útil recalcar, que conforme lo ha establecido el numeral 6.3 del artículo 6° de la LPAG, dispositivo que señala, que las fórmulas generales y vacías que se expongan en los actos administrativos no constituyen una debida motivación, aspecto del cual adolece la precitada carta y resolución emitidas por la demandada. Situación por la cual no pueden tener efecto jurídico alguno, en tal sentido, resultan nulas conforme al numeral 2 del artículo 10° de la LPAG.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.26. Bajo tales criterios, corresponde pronunciarse respecto al contenido final de la pretensión, siendo razonable concluir que la demandante no ha incurrido en las penalidades descritas en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022 y "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022, por cuanto se ha determinado objetivamente que dichas conductas fueron subsanadas oportunamente ante la supervisión y por cuanto no se ha seguido el procedimiento indicado por el contrato y las bases integradas, por lo que en razón a la función declarativa del laudo arbitral, corresponde declarar absuelto al demandante de los cargos y las conductas por las que se le penalizara mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH.

7.27. Considerando lo hasta aquí expuesto y dado que tanto la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C y la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH carecen de valor jurídico y legal, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no declarar nula y sin efecto legal la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C emitidas por la Municipalidad Distrital de Chamaca, por la que resuelven aplicarnos penalidades por la suma de S/ 145,456.13 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 13/100 soles); y en su lugar se declare absuelto al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en los ítems 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, así como de los hechos descritos en el Acta de Verificación de Obra N° 04 de fecha 18 de febrero de 2022 y Acta de Verificación de Obra N° 05 de fecha 01 de abril de 2022.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.28. La demandante señala que con fecha 28 de diciembre de 2022 se le notifica, vía correo electrónico, la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C de fecha 23 de diciembre de 2022 (carta que no fue diligenciada notarialmente), adjuntando la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH de fecha 23 de diciembre de 2022, con la que se le aplica penalidad por un monto de S/ 145,456.13 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Cincuenta y Seis con 13/100 Soles), por la supuesta comisión de las infracciones contenidas en los ítems 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, y cuyo sustento se encuentra contenido en el Acta de Verificación de Obra N° 04 de fecha 18 de febrero de 2022 y Acta de Verificación de Obra N° 05 de fecha 01 de abril de 2022.

7.29. La demandante señala que la aplicación de dichas penalidades transgrede el procedimiento establecido por las bases integradas y el contrato, pues adolece de los siguientes vicios: i) No se ha registrado en cuaderno de obra las infracciones cometidas y las evidencias recabadas; ii) No se ha notificado al contratista la carta de preaviso de aplicación de penalidades; y iii) No se ha otorgado al contratista el plazo para subsanar la infracción.

7.30. Del mismo modo, la demandante señala que las penalidades transgreden el procedimiento establecido en los ítems 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, y el Capítulo III- Requerimiento, página 52 de las Bases Integradas.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

7.31. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 y constando la notificación a folios 406 del expediente arbitral, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7.32. Teniendo en cuenta los criterios doctrinarios y jurídicos establecidos en los fundamentos 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12 y 7.13 de la presente resolución, la controversia está referida a la aplicación de "otras penalidades" distintas a la penalidad por mora, materializadas a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH, razón por la cual el tribunal procede a verificar si la misma ha sido aplicada observando los requisitos señalados por el artículo 134 del RLCE, esto es, que se haya cumplido con incluir los supuestos de aplicación de la penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

7.33. Respecto a los supuestos de aplicación de esas "otras penalidades": para nuestro caso, la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

GM/MDCH-CH, imputa la comisión de las infracciones señaladas en los numerales 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del contrato:

TABLA DE PENALIDADES - CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	PROCEDIMIENTO	FORMA DE CALCULO
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del inspector o supervisor designado	0.0002*M (por día)
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su oferta técnica	Según informe del inspector o supervisor designado	0.0002*M (por día y ocurrencia)

TABLA DE PENALIDADES - CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS					
N°	DEFINICIÓN	CALCULO	M = MONTO CONTRACTUAL	NUMERO DE DÍAS O NUMERO DE VECES DE OCURRENCIA	TOTAL \$/.
13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	0.0002*M (por día)	20,779,448.24	1	41,558.89
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su oferta técnica	0.0002*M (por día y ocurrencia)	20,779,448.24	5	101,897.89
TOTAL					\$/ 145,456.13

7.34. Por su parte, los numerales 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato enumeran los supuestos a penalizar:

13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.002*M (Por día)
----	---	---	-------------------

22	No cumple con proveer con el personal establecida en su Oferta Técnica	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0010*M (Por ocurrencia)
----	--	---	---------------------------

7.35. Como podrá observarse, es el contrato en sí mismo, a través de su Cláusula Décimo Quinta, quien delimita y enumera los supuestos a penalizar, no advirtiéndose contradicción o vicios sobre su contenido textual ni sobre los supuestos invocados por la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH, pues resultan claras las conductas a ser sancionadas, concluyéndose que las penalidades aplicadas si cumplen con este presupuesto.

7.36. Respecto a la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto: Sobre este presupuesto, deberemos remitirnos nuevamente a los numerales 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, por cuanto en ellas se especifica la forma de cálculo de cada supuesto penalizable, así tenemos que:

13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.002*M (Por día)
----	---	---	-------------------



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

22	No cumple con proveer con el personal establecida en su Oferta Técnica	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0010*M (Por ocurrencia)
----	--	---	---------------------------

7.37. Como podrá observarse, es el contrato en sí mismo, a través de su Cláusula Décimo Quinta, quien especifica claramente la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto, no advirtiéndose contradicción o vicios sobre su contenido textual ni sobre el cálculo realizado por la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH, concluyéndose que las penalidades aplicadas si cumplen con este presupuesto.

7.38. Respecto al procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar: Sobre este presupuesto, deberemos remitirnos nuevamente a los numerales 8, 13 y 22 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato, por cuanto en ellas se especifica el procedimiento de verificación, así tenemos que:

13	No permanencia de cuaderno de obra en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.002*M (Por día)
22	No cumple con proveer con el personal establecida en su Oferta Técnica	Según informe del Inspector o Supervisor designado.	0.0010*M (Por ocurrencia)

7.39. Del mismo modo, las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 002-2017-MDCH-CH, en su Capítulo III- Requerimiento, página 52, señalan que:

OTRAS PENALIDADES

Las consideraciones de la aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas obligaciones a cargo de El Contratista distintas al retraso, cuyas consideraciones están definidas en el artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de penalidades – contrato de obras, registra la infracción en el cuaderno de obras, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso a El Contratista; de igual forma un representante de la Entidad que administra el contrato puede advertir la falta mediante carta de preaviso al Contratista, estableciéndole un plazo para la subsanación de la infracción. En caso se advierta, del cuaderno de obra, la reincidencia de infracciones, el Supervisor calculara directamente la penalidad.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, El supervisor procede a calcular la penalidad según la tabla establecida de penalidades sobre un porcentaje del monto contractual, por día, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.40. Como podrá observarse, tanto las bases integradas como el contrato, en ambos documentos se ha indicado el procedimiento para la aplicación de esas "otras penalidades", sin embargo, realizando un análisis del sentido de tales documentos se puede advertir que las Bases Integradas complementan al Contrato en sí mismo, ya que del texto de ambas no se aprecia contradicciones o incongruencias procedimentales, al contrario, las Bases Integradas hacen un desarrollo un poco más amplio del procedimiento a seguir en caso se presenten o se configuren estos hechos penalizables; en buena cuenta y dada la complementariedad del contrato y los documentos que la conforman, podemos enumerar el procedimiento establecido por el contrato para la aplicación de esas "otras penalidades":

- e) El supervisor registra la infracción en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias de los hechos penalizables.
- f) El supervisor remite un preaviso al contratista, otorgándole un plazo para la subsanación de la infracción.
- g) En caso de no subsanar la infracción, el supervisor procede a emitir informe sobre las penalidades a aplicarse, haciendo el cálculo respectivo, verificando antes que no se haya alcanzado el tope máximo de penalidades.
- h) En caso de verificarse en el cuaderno de obra la reincidencia del contratista, se aplican las penalidades directamente mediante informe del supervisor.

7.41. Entonces, revisando el procedimiento seguido por la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH y los documentos que la sustentan, tales como el Acta de Verificación de Obra N° 04 de fecha 18 de febrero de 2022 y Acta de Verificación de Obra N° 05 de fecha 01 de abril de 2022, Carta N° 31-2022-REPLEGLA/SIUCH de fecha 10 de febrero de 2022, Informe N° 183-2022-BJBH-OSELO/MDCH de fecha 09 de mayo de 2022, Informe N° 0485-2022-CHVM/SGIDUR-MDCH-CUSCO de fecha 10 de mayo de 2022, Informe N° 038-2022-RJTE-OLyBP/MDCH-C de fecha 25 de mayo de 2022, Informe N° 19-2022-OAL-MDCH-HHCM, Informe N° 1584-2022-CHVM/SGIDUR-MDCH-CUSCO de fecha 13 de diciembre de 2022, Informe N° 183-2022-BJBH-OSELO/MDCH, Informe N° 049-2022-RMP-OLYBP/MDCH-C de fecha 15 de diciembre de 2022, y Opinión Legal N° 300-2022-OAL-MDCH-HHCM de fecha 22 de diciembre de 2022, de ninguna de ellas se observa que se haya seguido el procedimiento indicado en el fundamento 7.40 de la presente resolución.

7.42. En esa lógica, la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH en sí misma y la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

CH/C, como medio para dar a conocer una determinada situación jurídica al demandante, adolecen de la debida motivación; dado que todo acto administrativo esté contenido en una carta, oficio o resolución administrativa debe considerar las razones, lógica y razonamiento de la decisión que ha tomado el funcionario que emite el resolutivo, en otros términos, exponer en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada, es útil recalcar, que conforme lo ha establecido el numeral 6.3 del artículo 6° de la LPAG, dispositivo que señala, que las fórmulas generales y vacías que se expongan en los actos administrativos no constituyen una debida motivación, aspecto del cual adolece la precitada carta y resolución emitidas por la demandada. Situación por la cual no pueden tener efecto jurídico alguno, en tal sentido, resultan nulas conforme al numeral 2 del artículo 10° de la LPAG.

7.43. Bajo tales criterios, corresponde pronunciarse respecto al contenido final de la pretensión, siendo razonable concluir que la demandante no ha incurrido en las penalidades descritas en el Acta de Verificación de Obra N° 04 de fecha 18 de febrero de 2022 y Acta de Verificación de Obra N° 05 de fecha 01 de abril de 2022, por cuanto se ha determinado objetivamente que no se ha seguido el procedimiento indicado por el contrato y las bases integradas, por lo que en razón a la función declarativa del laudo arbitral, corresponde declarar absuelto al demandante de los cargos y las conductas por las que se le penalizara mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH.

7.44. Considerando lo hasta aquí expuesto y dado que tanto la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C y la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH carecen de valor jurídico y legal, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, la devolución y/o reembolso a favor del contratista, del monto de S/ 128,832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles) indebidamente descontados, más los intereses generados hasta la fecha.

Resumen de la posición del DEMANDANTE



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.45. La demandante señala que, habiéndose determinado que la demandada ha procedido de forma irregular al emitir la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, esto es, aplicando penalidades sin observar el debido procedimiento estipulado en los ítems 8, 13 y 22 de la Clausula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, y el Capítulo III- Requerimiento, página 52 de las Bases Integradas, ello origina a su vez el derecho de restituir, rembolsar y/o devolver al contratista el monto indebidamente retenido de las valorizaciones.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

7.46. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 y constando la notificación a folios 406 del expediente arbitral, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7.47. Ahora bien, el presente punto controvertido esta referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor de la demandante, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA⁷, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

7.48. Así pues, tratándose de prestaciones reciprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista; tal como ha señalado la Opinión N° 116-2016/DTN en su numeral 2.2, que dice:

⁷ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28. <https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

7.49. Entonces, tratándose de obligaciones reciprocas vinculadas en razón de un contrato administrativo, en lo concerniente al contratista se ha generado el derecho de recibir la contraprestación convenida por lo realmente ejecutado, ya que en palabras de ARNAU MOYA⁸: "... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004). El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000).

El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (Pérez Álvarez, 2000):

- La extinción de las obligaciones. Si bien las obligaciones también se extinguen por otras causas.

⁸ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 44.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

- La liberación del deudor. Lo que supone que desaparece el deber jurídico de llevar a cabo la prestación.
- La satisfacción del interés del acreedor. Puesto que el cumplimiento supone la consecución de la prestación que se le podía exigir al deudor.

El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).

El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente...

7.50. Para el presente caso, este tribunal arbitral ha determinado previamente que tanto la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH como la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C, ambas adolecen de la debida motivación sancionada con la nulidad, entonces, se ha enervado o restaurado nuevamente el derecho del demandante en obtener la contraprestación por los trabajos efectivamente ejecutados y contenidos en la valorización debidamente aprobada por la supervisión, valorización que al tener la naturaleza de pago a cuenta- según el artículo 166 del RLCE-, implica adelantar de manera anticipada antes de realizar el abono de una deuda final, entonces, se ha generado la obligación de la demandada de abonar a favor del demandante, el monto retenido o descontado por concepto de penalidades, como consecuencia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH, anulada en sede arbitral.

7.51. Por otro lado, la demandante también ha solicitado que se le reconozca el pago de los intereses generados por el indebido descuento en razón de las penalidades ya desestimadas en sede arbitral, para lo cual debemos de remitirnos a lo señalado por el artículo 39° de la LCE, la cual señala:

“... Artículo 39. Pago

39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato.

39.3 ***En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora...***

7.52. Bajo dicho contexto, se tiene que la normativa en contrataciones del Estado, ha previsto el reconocimiento de intereses legales ante la demora en el pago de las retribuciones en favor del contratista, salvo razones de hecho fortuito o fuerza mayor, situación que en el presente caso resulta evidente que no ha sucedido, siendo la raíz de la omisión del pago en favor del DEMANDANTE el irregular accionar de la DEMANDADA durante el procedimiento y posterior arbitraje para dilucidar la controversia, razones por las que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 39.3 del artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.53. También es necesario dejar por sentado, que el DEMANDANTE ha solicitado el pago de intereses generados a la fecha, es decir calculados a la fecha de presentación de la demanda arbitral, esto es al 30 de marzo de 2023, siendo la fecha de inicio de generación de intereses la fecha en la que debió efectuarse el pago del monto retenido indebidamente, que para el presente caso es la fecha de notificación con la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C. Para ello, la A-Quo recurre a la Cláusula Cuarta del Contrato de Ejecución de Obra de fecha 24 de noviembre del 2017, para mayor énfasis procedemos a efectuar su transcripción:

"... CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

(...) En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes..."

7.54. En ese entendido, se tiene que la fecha en que debió efectuarse el pago fue el 05 de setiembre de 2022, conforme al cargo de notificación vía correo



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

electrónico de la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C que obra en autos.

7.55. En ese sentido, la Árbitro Único a efectos de calcular el monto de los intereses legales generados, ha recurrido a la calculadora⁹ del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estableciendo mediante dicha herramienta que los intereses legales ascienden al monto de: S/ 2,220.40 (Dos Mil Doscientos Veinte con 40/100 Soles), debiendo reconocerse a favor del DEMANDANTE el pago de dicha suma.

7.56. Considerando lo hasta aquí expuesto y dado que tanto la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C y la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH carecen de valor jurídico y legal, lo que a su vez implica reponer el derecho de pago a favor del demandante por las prestaciones ejecutadas a favor del demandado, entonces, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, la devolución y/o Reembolso a favor del contratista, del monto de S/ 145,456.13 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con 13/100 soles) indebidamente descontados, más los intereses generados hasta la fecha.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.57. La demandante señala que, habiéndose determinado que la demandada ha procedido de forma irregular al emitir la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH, esto es, aplicando penalidades sin observar el debido procedimiento estipulado en los ítems 13 y 22 de la Clausula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, y el Capítulo III- Requerimiento, página 52 de las Bases Integradas, ello origina a su vez el derecho de restituir, rembolsar y/o devolver al contratista el monto indebidamente retenido de las valorizaciones.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

⁹ <https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.58. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 y constando la notificación a folios 406 del expediente arbitral, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7.59. Tal como fundamentamos en los numerales precedentes, el presente punto controvertido esta referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor de la demandante, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA¹⁰, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

7.60. Así pues, tratándose de prestaciones reciprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista; tal como ha señalado la Opinión N° 116-2016/DTN en su numeral 2.2, que dice:

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las

¹⁰ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

7.61. Para el presente caso, este tribunal arbitral ha determinado previamente que tanto la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH como la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C, ambas adolecen de la debida motivación sancionada con nulidad, entonces, se ha enervado o restaurado nuevamente el derecho del demandante en obtener la contraprestación por los trabajos efectivamente ejecutados y contenidos en la valorización debidamente aprobada por la supervisión, valorización que al tener la naturaleza de pago a cuenta- según el artículo 166 del RLCE-, implica adelantar de manera anticipada antes de realizar el abono de una deuda final, entonces, se ha generado la obligación de la demandada de abonar a favor del demandante, el monto retenido o descontado por concepto de penalidades, como consecuencia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH, anulada en sede arbitral.

7.62. Por otro lado, la demandante también ha solicitado que se le reconozca el pago de los intereses generados por el indebido descuento en razón de las penalidades ya desestimadas en sede arbitral, para lo cual debemos de remitirnos a lo señalado por el artículo 39° de la LCE, la cual señala:

"... Artículo 39. Pago

39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.

39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora...

7.63. Bajo dicho contexto, se tiene que la normativa en contrataciones del Estado, ha previsto el reconocimiento de intereses legales ante la demora en el pago de las retribuciones en favor del contratista, salvo razones de hecho fortuito o fuerza mayor, situación que en el presente caso resulta evidente que no ha sucedido, siendo la raíz de la omisión del pago en favor del DEMANDANTE el irregular accionar de la DEMANDADA durante el procedimiento y posterior arbitraje para dilucidar la controversia, razones por las que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 39.3 del artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.64. También es necesario dejar por sentado, que el DEMANDANTE ha solicitado el pago de intereses generados a la fecha, es decir calculados a la fecha de presentación de la demanda arbitral, esto es al 30 de marzo de 2023, siendo la fecha de inicio de generación de intereses la fecha en la que debió efectuarse el pago del monto retenido indebidamente, que para el presente caso es la fecha de notificación con la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C. Para ello, el árbitro recurre a la Cláusula Cuarta del Contrato de Ejecución de Obra de fecha 24 de noviembre del 2017, para mayor énfasis procedemos a efectuar su transcripción:

"... CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

(...) En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes..."

7.65. En ese entendido, se tiene que la fecha en que debió efectuarse el pago fue el 28 de diciembre de 2022, conforme al cargo de notificación vía correo electrónico de la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C que obra en autos.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.66. En ese sentido, la Ábitro Único a efectos de calcular el monto de los intereses legales generados, ha recurrido a la calculadora¹¹ del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estableciendo mediante dicha herramienta que los intereses legales ascienden al monto de: S/ 1,209.26 (Mil Doscientos Nueve con 26/100 Soles), debiendo reconocerse a favor del DEMANDANTE el pago de dicha suma, tal como mostramos a continuación:

7.67. Considerando lo hasta aquí expuesto y dado que la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C carecen de valor jurídico y legal, implica reponer el derecho de pago a favor del demandante por las prestaciones ejecutadas a favor del demandado, entonces, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que se ordene a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral, así como los gastos del abogado patrocinante del demandante.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.68. La demandante señala que, dado que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá dichos pagos, teniendo en cuenta la renuencia de la demandada en asumir los costos del 50% de los gastos que le corresponden por el proceso arbitral, corresponde que se le imponga el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso, tanto más, si el Art. 166 del **RLCE** señala que: "si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados".

7.69. Adicionalmente, solicita que se aplique lo señalado por el numeral 32 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 16 de marzo de 2023, que dice:

"... 32. Sin perjuicio que el Tribunal Arbitral (Arbitro Único) pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..."

Resumen de la posición de la DEMANDADA

¹¹ <https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html>



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

7.70. La Arbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023/CACI/AU/HITS/HCO de fecha 25 de abril de 2023 y constando la notificación a folios 406 del expediente arbitral, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7.71. En lo que respecta al presente punto controvertido, es necesario señalar que la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, ello es de conformidad al numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, para mayor énfasis transcribimos la citada disposición:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..."

7.72. Por su parte, los numerales 31 y 32 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 16 de marzo de 2023, establece:

"... 31. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Tribunal Arbitral (Arbitro Único) se pronuncie al



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último solo se resolverá a petición de parte.

32. Sin perjuicio que el Tribunal Arbitral (Arbitro Único) pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..."

7.73. Atendiendo a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

7.74. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado tres pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que la demandada ha sido la responsable de las consecuencias jurídicas del presente proceso, lo que a su vez ha originado que el demandante tenga que recurrir ante sede arbitral para enervar su derecho, por lo que en aplicación del numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, este tribunal considera atendible imputar sobre la demandada el 100% de la obligación de pago de los costos arbitrales, precisándose que al haber efectuado la demandante el pago de la totalidad de los costos arbitrales, entonces, corresponde que se le reembolse dicho monto.

7.75. Por otro lado, respecto a los gastos incurridos por las partes para su defensa en el presente proceso arbitral, teniendo en cuenta que el derecho a la defensa se configura como una actividad necesaria para cualquier litigio, entonces, resultaría injusto que se le atribuya el pago de tales servicios personalísimos a su contraparte, más aún si tenemos en cuenta que en autos no obra el recibo por honorarios del abogado patrocinante, ni de documento que lo sustente.

7.76. Considerando lo hasta aquí expuesto, entonces, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** el presente punto controvertido, haciendo la precisión que los gastos por el abogado patrocinante de la demandante serán asumidos únicamente por ésta.

8. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho, **LAUDA:**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

PRIMERO. - Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Principal, por lo que se declara **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 046-2022-GM/MDCH-CH/C emitidas por la Municipalidad Distrital de Chamaca, con la que aplican penalidades por la suma de S/128, 832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles); asimismo, declarándose **ABSUELTO** al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en los numerales 8, 13 y 22 de la Clausula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, así como de los hechos descritos en el "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 11 de mayo de 2022 y "Acta de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave que Labora Directamente en Obra" de fecha 16 de mayo de 2022; conforme a los argumentos expuestos.

SEGUNDO. - Declarar **FUNDADA** la Segunda Pretensión Principal, por lo que se declara **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la Resolución de Gerencia Municipal N° 186-2022-GM/MDCH-CH y la Carta Notarial N° 088-2022-GM/MDCH-CH/C emitidas por la Municipalidad Distrital de Chamaca, con la que aplican penalidades por la suma de S/ 145,456.13 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 13/100 Soles); asimismo, declarándose **ABSUELTO** al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en los numerales 13 y 22 de la Clausula Décimo Quinta del Contrato de Ejecución de Obra, así como de los hechos descritos en el Acta de Verificación de Obra N° 04 de fecha 18 de febrero de 2022 y Acta de Verificación de Obra N° 05 de fecha 01 de abril de 2022; conforme a los argumentos expuestos.

TERCERO. - Declarar **FUNDADA** la Pretensión Accesorio a la Primera Pretensión Principal, por lo que **SE ORDENA** a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, la devolución y/o reembolso a favor del demandante de la suma de **S/ 128,832.58 (Ciento veintiocho mil ochocientos treinta y dos con 58/100 soles)** indebidamente descontados, más los **INTERESES LEGALES** generados hasta la fecha de presentación de la demanda por la suma de **S/ 2,220.40 (Dos Mil Doscientos Veinte con 40/100 Soles)**; conforme a los argumentos expuestos.

CUARTO. - Declarar **FUNDADA** la Pretensión Accesorio a la Segunda Pretensión Principal, por lo que **SE ORDENA** a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca, la devolución y/o reembolso a favor del demandante de la suma de **S/ 145,456.13 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 13/100 Soles)** indebidamente descontados, más los **INTERESES LEGALES** generados hasta la fecha de presentación de la demanda, la misma que deberá ser calculados al monto de requerirse y ejecutarse el laudo por la suma de **S/ 1,209.26 (Mil Doscientos Nueve con 26/100 Soles)**; conforme a los argumentos expuestos.



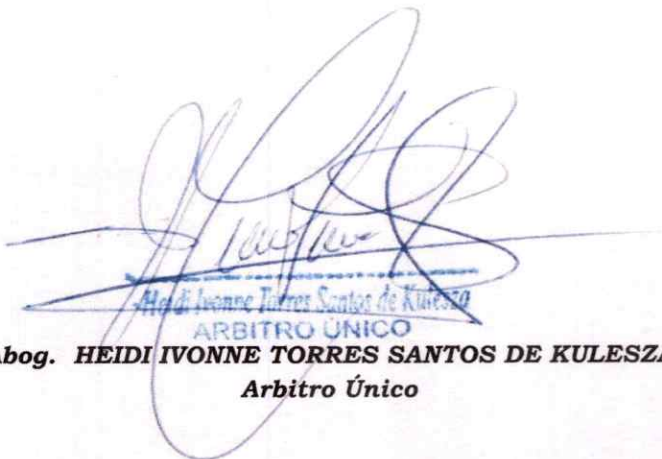
CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

QUINTO. - Declarar **FUNDADA EN PARTE** la Tercera Pretensión Principal, por lo que **SE ORDENA** a la demandada Municipalidad Distrital de Chamaca que asuma el pago de la totalidad de las costas del proceso arbitral por la suma de **S/13,171.87 (Trece Mil Ciento Setenta y Uno con 87/100 Soles)**, los mismos que deberán ser reembolsados a favor de la demandante; e **INFUNDADA** en cuanto al pago de los costos del abogado patrocinante del demandante; conforme a los argumentos expuestos.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en sus respectivos domicilios procesales electrónicos, así como se cumpla con registrar en el portal del SEACE conforme al art. 194° del RLCE, bajo responsabilidad. -

Firmado:


 Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
 ARBITRO UNICO
Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
 Arbitro Único


 Katy Lina Cadillo Valenzuela
 SECRETARIA ARBITRAL
Abog. KATY LINA CADILLO VALENZUELA
 Secretaria Arbitral